

1500027-46.2020.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Centro - CEP 11750-000, Fone: (13) 3455-3629, Peruíbe-SP - E-mail: peruibe2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1500027-46.2020.8.26.0441 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Data da Audiência:

19/01/2022 às 15:45h

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HENRIQUE MESSIAS SILVA e outro

Vistos.

VICTOR HENRIQUE MESSIAS SILVA e FRED DA COSTA SOUZA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal, porque teriam, no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 15h:30m, na Rua Rubens Ferreira Martins, nº 462, Estação, nas dependências da Delegacia de Peruíbe, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraído, em proveito comum, um módulo de som veicular, marca Gooling Fan, cor azul e cromado, usado, avaliado em R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

Recebida a denúncia (fls. 129/130), os réus foram regularmente citados (fls. 176 e 179) e apresentaram resposta à acusação por meio de advogado dativo (fls. 187/188 e 196/197), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 199/200).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações de duas testemunhas da acusação, tendo sido os réus interrogados.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado Vitor, nos termos da denúncia, e a absolvição do acusado Fred; pleiteou a defesa de Fred a absolvição; a defesa de Victor requereu a fixação de pena no mínimo, compensada reincidência por confissão, em regime brando, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos

demonstra com clareza a materialidade, pelo auto de exibição de fls. 12, relatório de investigação de fls. 27/28 e prova oral produzida em juízo, que apontam a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria em relação ao réu Victor Henrique.

Eis a prova produzida:

O policial civil ANDERSON CARLOS LOMENZO BUONO relatou em Juízo que receberam na delegacia diversos detentos, a partir de convênio, para a realização de serviços de pintura. O Fred era um desses detentos. Ouviram comentários de que estavam sendo levados entorpecentes para a cadeia, por meio do vulgo "Toddy", que é o Vitor. Foram à oficina do tio dele, que fica na frente da Delegacia. Conversaram com ele e o tio disse que uma senhorita havia deixado uma sacola para entregar ao Toddy. Conversaram com o Toddy, que confessou que tinha recebido os entorpecentes da pessoa de Fred. Ele tinha um Voyage. Dentro do veículo, foram encontrados os entorpecentes e o módulo de som. Em outra data, um policial viu o Vitor pegando o módulo de som embaixo de um veículo. O Vitor disse que o Fred tinha retirado o som e deixado embaixo do veículo. O Fred sempre negou. O Vitor colaborou. Não viu o furto. Acredita que foi o policial Vinicius Pane que viu o Fred furtando o módulo. Quem lhe informou do furto foi o Vitor. As câmeras de monitoramento estavam todas quebradas. Estão tentando arrumar, mas não tem as imagens. Eram diversas pessoas que prestavam serviços no local. Não havia outro Fred prestando serviço, só esse mesmo. Não se recorda o nome das demais pessoas que prestavam serviços no local. O policial civil MARCUS VINICIUS PANE DE SOUZA descreveu em Juízo que estava sozinho e viu o Vitor retirar alguma coisa da parte debaixo do carro, que estava apreendido em um terreno ao lado da delegacia, que não possui pátio. Não abordou o Vitor pois estava sozinho. Ele subiu em uma moto e o perdeu de vista. No dia seguinte, foram conversar com o Vitor na loja do tio dele, que ficava em frente à Delegacia. Ele colaborou. Disse que os presos do semiaberto que prestavam serviço na delegacia lhe pediram para pegar o módulo. Mencionou que quem teria pedido era o Fred. Ele indicou o local em que estava o módulo, no veículo dele, onde o objeto foi encontrado juntamente com drogas, que são objeto de outro processo. Na época, não havia monitoramento por câmeras no local. Tinha alguém no local que coordenava os presos. Não se lembra se havia outro Fred. Não viu ninguém retirando o aparelho do veículo, viu apenas o Vitor pegando o aparelho embaixo do carro.

O réu FRED DA COSTA SOUZA SILVA, ouvido em Juízo, disse que o Vitor lhe disse que tinha um carro apreendido e perguntou se poderiam ajudá-lo a tirar o som de um carro. Seguiu trabalhando na delegacia, pintando. No dia, disse ao Vitor que o som estava debaixo de um carro. Apenas isso. Não tirou o som do veículo.

O réu VICTOR HENRIQUE MESSIAS SILVA, ouvido em Juízo, afirmou que o módulo de som veicular estava debaixo do carro. Lhe disseram para pegar, foi lá, pegou e levou embora. Está arrependido.

A confissão prestada em Juízo pelo réu Victor, de espontaneidade inquestionável, não destoa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

É certo que o depoimento de policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

"É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante.

Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 - e-book). O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

"A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485.543 - SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem os fatos quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem. As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes e harmônicos entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial acerca do ocorrido. Coerentes e precisos, expostos de forma coesa e lógica, merecem credibilidade os depoimentos das testemunhas. Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que as testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu.

É cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada das testemunhas e pela espontânea confissão do réu, de tal sorte que materialidade e autoria do delito se encontram perfeitamente comprovadas.

A comparsaria restou evidente, compreendendo-se da própria conduta, caracterizada por atuação concatenada entre dois agentes com repartição de atos de execução, o ajuste de vontades entre eles, caracterizada participação equivalente e igualmente importante de todos, ademais relevante a circunstância para incrementar o potencial de êxito da empreitada, incidindo a qualificadora. Nesse ponto, o próprio réu Victor confessou que não foi ele quem retirou o módulo de som do veículo, mas outra pessoa, que o avisou onde o objeto estava para que fosse retirado. O réu, então, de posse da informação, consumou a subtração, retirando o objeto que estava embaixo do veículo e tomando rumo sem que fosse incomodado.

O réu não é primário, de modo que não se aplica ao caso o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, a despeito do pequeno valor da coisa.

É certo que a consumação foi atingida, desde que conquistada e aproveitada, ainda que por tempo breve, posse desviada da res, levada pelo agente quando tomou rumo sem que ninguém o perturbasse, resultando a subsequente recuperação da res de casual intervenção policial bem-sucedida, já inserida em desenrolar causal autônomo.

A conduta é típica, não tendo a res valor insignificante ou ínfimo, apta a conduta a produzir lesão patrimonial, a par de encerrar em si desvalor social que reclama intervenção estatal.

A condenação de Victor Henrique Messias Silva é de rigor.

Por outro lado, com relação ao réu FRED DA COSTA SOUZA SILVA, da análise detida dos autos, verifica-se que não foram produzidas, em Juízo, provas suficientes para embasar a condenação.

Nesse ponto, observo que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou a subtração imputada ao réu Fred. Ambos os policiais disseram que chegaram a Fred após a informação obtida com Victor. Este, contudo, em audiência, não declinou o nome de Fred como sendo seu comparsa, permanecendo em silêncio nesse ponto.

O réu Fred, por sua vez, negou que tenha subtraído o módulo de som veicular. O prolação de decreto condenatório pressupõe a existência de prova inequívoca da materialidade e da autoria do delito que motivou a instauração do processo penal. Prova, no direito brasileiro, é aquela produzida em contraditório judicial, razão pela qual, a teor do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: "Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José da Costa Rica, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

Não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após a instrução do feito, analisar se as provas produzidas são bastantes para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Persistindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos mesmo após a instrução, não se atinge o padrão ("standard") probatório exigido para ensejar uma condenação.

"Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de verossimilhança, de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois é apta a superar a barreira do "acima da dúvida razoável" e consegue dar conta do nível de exigência da garantia da presunção de inocência" (Junior, Aury Celso Lima L. DIREITO PROCESSUAL PENAL. Editora Saraiva, 2021 e-book).

Nesse caso, aplica-se a máxima segundo a qual a dúvida favorece o réu, em decorrência da presunção de inocência. A propósito, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça:

1-) Apelação criminal. Furto tentado. Sentença absolutória. Inconformismo da Acusação. 2-) Materialidade duvidosa. As provas colhidas nos autos deixam dúvida acerca da dinâmica do ocorrido e do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado, sendo que a dúvida deve favorecer o réu. Para proferir-se uma condenação criminal é preciso que haja prova escorreita e segura da existência do fato delituoso e de sua autoria para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida. E no caso em estudo, isso não ocorreu. 3-) Não provimento do recurso do Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1518063-

96.2020.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020).

Ademais, pleiteando o Ministério Público, em alegações finais, a absolvição do réu, não há alternativa ao juiz a não ser o decreto absolutório, em virtude da não recepção do art. 385 do Código de Processo Penal pela Constituição, por afronta ao sistema acusatório (art. 129, inc. I da CRFB).

No sistema acusatório, há completa separação entre as funções de acusar e julgar; o Juiz deve estar rigidamente separado das partes, com equidistância, em observância ao princípio da imparcialidade.

O pedido de absolvição veiculado pelo representante do Ministério Público, titular da ação penal, faz desaparecer a acusação. Em outras palavras, não subsiste a pretensão acusatória.

E, não havendo mais acusação por parte do titular da ação penal, eventual sentença condenatória resultaria no acúmulo das funções de acusar e punir por parte do magistrado.

Portanto, "viola o sistema acusatório constitucional a regra prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o juiz condenar ainda que o Ministério Público peça absolvição. Também representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão acusatória"

(LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal, 16ª Edição. São Paulo. Saraiva. 2019. P. 917).

Assim, de rigor a absolvição em relação ao réu FRED DA COSTA SOUZA SILVA.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado VICTOR HENRIQUE MESSIAS SILVA.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 155, § 4º, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois a culpabilidade do agente e os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não há elementos que denotem conduta social ou personalidade acentuadamente negativas; os antecedentes do réu não recomendam incremento da pena base; a vítima em nada concorreu para o delito.

Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 85/89, caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal pela confissão plena prestada pelo acusado, pelo que, atendido o entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a base inalterada.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição, torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime semiaberto, com fulcro no abrandamento da Súmula 269 do STJ dadas as circunstâncias judiciais favoráveis, porque adequado à consecução das finalidades da sanção penal. A reincidência do réu impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal, medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não são capazes de propiciar o escopo da punição.

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda

exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA".

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: "(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu VICTOR HENRIQUE MESSIAS SILVA por infração ao artigo 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal, às penas de 2 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ainda, ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado FRED DA COSTA SOUZA SILVA da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços, ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência.
Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 19 de janeiro de 2022.

CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Juiz Substituto